

1500582-04.2022.8.26.0438

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANO SANTOS DE LIMA

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DOS SANTOS PAGANI

Aos 27 de junho de 2022, às 14:45h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "3ª Vara de Penápolis - Audiência de Instrução - Proc. 1500582-04.2022.8.26.0438 - Dia 27/06/2022, às 14:45h", sob a presidência do MM. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Centro, Penápolis - 16300-000 - SP

13h00min às17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO VIRTUAL

Processo nº:

1500582-04.2022.8.26.0438 - 2022/000717

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO DOS SANTOS PAGANI

Aos 27 de junho de 2022, às 14:45h, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "3ª Vara de Penápolis - Audiência de Instrução - Proc. 1500582-04.2022.8.26.0438 - Dia 27/06/2022, às 14:45h", sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. JULIANO SANTOS DE LIMA, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe.

Cumpridas as formalidades legais observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Doutor Carlos Bruno Gaya da Costa, Promotor de Justiça atuante nesta Comarca; do acusado FABIANO DOS SANTOS PAGANI, recluso no CDP

de São José do Rio Preto/SP; do defensor, Dr. Felipe Tadeu Pereira Andolfato; e das testemunhas Fabrício Polon dos Santos e PM Bruno Prado de Oliveira. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e sua defensora conversa privativa, tendo o MM. Juiz, Dr. Promotor e demais participantes, momentaneamente deixado a sala virtual.

A seguir, retornando os participantes à sala virtual, procedeu-se ao início da audiência virtual.

Foram adicionadas, a partir do lobby, à audiência virtual, as testemunhas arroladas Fabrício Polon dos Santos e PM Bruno Prado de Oliveira, respectivamente, todas desconectadas da audiência virtual logo após seus respectivos depoimentos.

Em seguida, interrogou-se o réu.

Todos os depoimentos foram captados por equipamento de imagem e áudio através do programa Microsoft Teams e gravação realizada direto no SAJ, disponível no termo de audiência, para acesso às partes cadastradas.

O Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor disseram que não tinham mais provas a serem produzidas.

Pelo MM. Juiz de Direito foi determinado: "Vistos. Dou por encerrada a instrução, devendo as partes apresentarem suas alegações finais. Nada mais."

O Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor apresentaram suas alegações finais de forma oral.

Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: "Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FABIANO DOS SANTOS PAGANI, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Notificado, o réu apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida e sobreveio citação. Designada a presente audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento de duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o Órgão Ministerial requereu a procedência da pretensão condenatória manifestada na denúncia. A Defesa, a seu turno, requereu, em alegações finais, a absolvição por insuficiência probatória e, em caráter subsidiário, a desclassificação da conduta. É o relatório. Decido. Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência policial (fls. 8/10), auto de exibição/apreensão (fl. 12), laudo preliminar de constatação (fls. 15/21); laudo definitivo de exame químico-toxicológico, indicando que foi detectada a presença da substância cocaína no material analisado (fls. 190/192) e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual. A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscrito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações. A autoria também é certa e recai sobre o acusado. A testemunha Fabrício Polon dos Santos, policial militar, disse que estava de patrulhamento na área central; que avistou indivíduo em bicicleta na contramão; que chegou próximo ao cruzamento; que identificou Fabiano, o qual já era conhecido dos meios policiais; que efetuou buscas; que havia várias porções de entorpecentes no bolso de Fabiano, além da quantia de dois reais; que possuía informações de outros policiais de que Fabiano estava traficando na região central da cidade; que não sabiam as rotas de Fabiano. A testemunha Bruno Prado de Oliveira, policial militar, disse que estava em patrulhamento na área central da cidade; que era Fabiano, o qual estava de bicicleta; que Fabiano começou a acelerar; que conseguiu abordar Fabiano; que fez buscar pessoais; que havia invólucros com várias porções de crack no bolso de Fabiano; que Fabiano é conhecido dos meios policiais e não deu maiores detalhes sobre a droga que Fabiano é usuário e droga e estaria se dedicando à atividade de "vaporzinho" para sustentar seu vício. Em seu interrogatório, o réu disse que tem 42 anos; que possui quatro filhos; que é viciado em "crack"; que trazia consigo a droga descrita na denúncia; que, ao ser abordado, estava voltando do local onde tinha adquirido a droga; que adquiriu R\$ 200,00 e ganhou duas porções; que a droga adquirida era "crack", a qual seria para uso próprio; que comprou na frente do cemitério; que comprou de pessoa chamada "Barbosinha"; que usaria a droga até a madrugada; e que nunca praticou

tráfico de droga. Os policiais ouvidos em juízo relataram que abordaram Fabiano em via pública. Em posse dele havia as porções de crack apreendidas, com peso líquido de 3,6 gramas (fl. 16), além da quantia de R\$ 2,00 (dois reais). A prova produzida sob o crivo do contraditório comprova, sem qualquer dúvida, que Fabiano trazia consigo o entorpecente. Diante disso, devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, não há como se absolver o acusado por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP, ficando, desde logo, rejeitada a tese defensiva nesse sentido. Nada obstante, a tipificação do fato deve ser modificada, com a consequente desclassificação do delito imputado na denúncia, uma vez que as provas produzidas nos autos se mostram insuficientes para comprovar a traficância. Destaque-se que o réu, em sede de interrogatório, alegou que não comercializava drogas, utilizando-as apenas para consumo próprio. Ainda que a tese de consumo próprio seja recorrente em casos como o presente e que, não raro, os comerciantes de tóxicos também se caracterizem como usuários, verifica-se que a quantidade encontrada com o acusado, de fato, era diminuta (3,67 gramas, fl. 16), compatível com o consumo pessoal de um usuário mediano. Ressalte-se que o único elemento de prova a fundamentar a tese da destinação comercial da droga é a palavra dos agentes policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais afirmaram que tinha conhecimento de que o acusado se dedicava ao tráfico. Ocorre que, embora dotada de especial relevância, a narrativa dos policiais não pode embasar decreto condenatório por si só. Para tanto, seria necessário que outros indícios ou provas reforçassem a imputação realizada na denúncia – o que não aconteceu no caso. Ante essas circunstâncias, deve-se concluir que a droga encontrada com o réu, efetivamente, destinava-se para seu uso pessoal. Saliente-se que, no sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova quanto à tipicidade do fato imputado em ação penal pública incondicionada compete ao Ministério Público (artigo 156 do CPP). Logo, em havendo dúvida sobre a tipificação do fato, ante a insuficiência do conjunto probatório, cabe ao julgador conferir a interpretação que se afigure mais benéfica ao acusado, como corolário do "in dubio pro reo". De se ressaltar, por fim, que vetores previstos no artigo 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006 também apontam para o uso pessoal do agente, embora existam condenações criminais pretéritas. Por todos estes fatores, conclui-se não haver, no caso, provas seguras o suficiente acerca do destino da droga ao comércio, que permitiria a condenação com fulcro no artigo 33, caput, da Lei nº 11.340/2006. Assim, acolho o pleito da defesa para desclassificar a conduta cometida pelo acusado para o tipo previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.340/2006. No que diz respeito à individualização da pena, verifica-se que o tipo penal em apreço sujeita o condenado a pena máxima de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento a programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que o acusado já cumpriu mais de 03 (três) meses de prisão cautelar nos presentes autos, tendo em vista que a prisão em flagrante se deu em 25/03/2022 (fls. 1/2). Logo, já tendo sido cumprida reprimenda mais gravosa que a impositiva no caso, deixo de impor qualquer pena em desfavor do réu e, de plano, constato ser o caso de extinção da punibilidade, em consonância com o entendimento fixado no seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. ALEGADA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA NO PROCESSO PENAL. REGRA PROBATÓRIA DECORRENTE DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) 6. A conduta imputada pelo Ministério Público - dentre as várias previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (que é de conteúdo múltiplo) - foi a de trazer consigo "11 (onze) pedras de crack, divididas em papелotes individuais e escondidas em suas partes íntimas". Em nenhum momento, o acusado foi visto vendendo, expondo à venda ou oferecendo entorpecentes a terceiros. 7. Não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial do entorpecente localizado com o recorrente. Com efeito, não houve campanha policial para averiguação da conduta do recorrente, mas tão somente uma abordagem pessoal em virtude do fato de o coacusado - que conduzia a motocicleta - ter se evadido ao avistar a autoridade policial. 8. O Ministério Público - sobre quem pesa o ônus da prova dos fatos alegados na acusação - não

comprovou a ocorrência de mercancia ilícita da droga encontrada em poder do recorrente, ou que a tanto se destinava, de modo que remanesce somente a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, prevista no tipo do caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 9. Dada a primariedade do recorrente (conforme reconhecido na sentença), a reprimenda prevista para o delito de posse de drogas para consumo próprio - prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo - não pode superar o prazo de 5 meses (art. 28, § 3º, da Lei n. 11.343/2006). 10. Entretanto, o acusado respondeu ao processo cautelarmente privado de sua liberdade (desde sua prisão em flagrante, em 6/3/2017), e sua custódia preventiva foi mantida na sentença condenatória. 11. Como ele está preso a um lapso temporal superior ao da reprimenda que lhe seria imposta, deve ser reconhecida a extinção de sua punibilidade. 12. Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao réu para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, já cumprido o prazo máximo da sanção cabível - de modo até mais oneroso -, julgar extinta sua punibilidade. (STJ; REsp 1.769.822; Proc. 2018/0255557-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 27/11/2018; DJE 13/12/2018; Pág. 2163)". Deixo de fixar indenização mínima (artigo 387, IV, do CPP), por ausência de pedido da acusação e por se tratar de crime vago. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de condenar o réu FABIANO DOS SANTOS PAGANI pela prática do delito descrito no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006. Ato contínuo, consoante exposto na fundamentação, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado pelo cumprimento integral da pena, na forma do art. 109 da Lei de Execução Penal. Em razão da desclassificação da conduta e da extinção da punibilidade, torna-se incompatível a manutenção da prisão cautelar até o trânsito em julgado. Assim, revogo a prisão preventiva e autorizo que o réu recorra em liberdade. Expeça-se, imediatamente, alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo. Condeno o(a) sentenciado(a) ao pagamento das custas e despesas processuais. Declaro o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União, na forma do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, os quais deverão ser revertidos diretamente ao Funad. Transitada em julgado da presente condenação: A) destruam-se as amostras guardadas para contraprova, certificando nos autos, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006; B) coloquem-se os bens e valores perdidos (fl. 12) à disposição da União (Funad); C) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e D) lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência. Os presentes saem intimados. Cumpra-se."

O Dr. Promotor de Justiça, o Dr. Defensor e o Réu tomaram ciência da sentença e renunciaram o prazo recursal, transitando em julgado a sentença nesta data. Nada mais a ser tratado na referida audiência, foi determinado o encerramento deste termo, bem como o término desta videoconferência. As partes presentes neste ato tomaram ciência de todo teor deste termo de audiência, no qual consta apenas a assinatura digital do MM. Juiz. As partes dispensaram a apresentação de cópia do termo de audiência. Eu, MARIANA FERREIRA VIEIRA, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA